

1500439-27.2021.8.26.0607

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Patrícia da Conceição Santos

Comarca: Tabapuã

Foro: Foro de Tabapuã

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 02/03/2022

... e assim ser possível, teoricamente, alegar o tráfico privilegiado, como sói acontecer em casos de grandes apreensões como o que ora se apresenta. Chama a atenção que a quantidade e natureza da droga induz, inclusive, à profissionalização do acusado no narcotráfico, considerando que as organizações criminosas afetas ao tráfico de entorpecentes, ao captarem pessoas para o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tabapuã

Foro de Tabapuã

Vara Única

Rua Eugenio Ulian, 1265, Tabapua - SP - cep 15880-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500439-27.2021.8.26.0607 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500439-27.2021.8.26.0607

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ISMAEL ALMEIDA RIBEIRO

Tramitação prioritária

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra ISMAEL ALMEIDA RIBEIRO (fl. 21) dando-o como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque ele, no dia 14 de setembro de 2021, as 17h00, na Rodovia SP 310, KM 398+500m, Catiguá, Ismael Almeida Ribeiro transportava 25 (vinte e cinco) tijolos de cocaína na forma de crack, com peso líquido de 24,75kg (cf. auto de exibição apreensão (fl. 17), laudo de constatação de fls. 09/21 e laudo toxicológico definitivo de fls. 244/246, destinado a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Houve a prisão em flagrante delito (fl. 05).

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 48/54).

A denúncia foi recebida em 07 de outubro de 2021 (fls. 108/109).

Citado (fl. 173), o acusado apresentou resposta à acusação (fls. 125/142).

Ratificou-se o recebimento da denúncia (fls. 174/176) e designou-se audiência de instrução e julgamento.

Durante audiência ouviram-se as testemunhas de acusação e, em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

O Ministério Público, em memoriais orais, pediu a procedência da ação penal, porque estariam provados os fatos descritos na denúncia.

A Defesa pugnou pela absolvição do acusado e, subsidiariamente, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, com aplicação do §4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, concessão do direito de recorrer em liberdade ou prisão domiciliar (fls. 231/240). Os autos vieram-me conclusos para sentença.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O processo encontra-se formalmente em ordem, não havendo nulidades ou vícios a sanar. O acusado foi representado por Defensor, com estrita observância aos princípios do devido processo legal, mormente o contraditório e a ampla defesa. À minguia de questões processuais ou preliminares arguidas, passo ao exame do mérito.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

Durante a persecutio criminis, o Ministério Público conseguiu demonstrar a existência do crime mediante boletim de ocorrência (fls. 12/15), auto de prisão em flagrante (fl. 05), nota de culpa (fl. 11), auto de exibição e apreensão (fl. 17), laudo de constatação (fls. 19/21), laudo toxicológico definitivo (fls. 244/246) e relatório final (fls. 99/101), tendo sido todos esses documentos confirmados por coerente prova oral; quanto à autoria, esta também ficou demonstrada por robusta e uniforme prova testemunhal.

Com efeito, a testemunha Everton aparecido Pereira dos Santos declarou, na delegacia, que se encontrava em serviço no pedágio de Catiguá, realizando bloqueio de fiscalização de rotina, quando avistaram um veículo Montana na qual o condutor ficava olhando em direção aos policiais para ver se seria abordado, aparentando ter se assustado com o bloqueio e assim mandaram o condutor parar o veículo logo após ele passar o pedágio sentido Catanduva, quando então mandaram o condutor descer do veículo e realizaram a busca pessoal, sendo que nada de ilegal foi encontrado. Disse que o condutor foi inquirido sobre de onde vinha e para onde estaria indo, bem como solicitada a documentação do veículo, ele apresentou documentação em ordem, mas ora dizia que vinha de Santa Fé do Sul ora que vinha de São José do Rio Preto, dizendo que estava voltando para Hortolândia, de onde tinha saído na data dos fatos. Afirmou que o réu que aparentava nervosismo e dizia que tinha ido visitar a tia da mulher dele, sendo que ele estava sozinho no veículo, quando então foram revistar o veículo e encontraram vinte e cinco tijolos de substância aparentando ser crack. Quando indagado, o autor, identificado como Ismael, alegou que parou em uma residência onde almoçou na cidade de Santa Fé do Sul e alguns rapazes saíram com seu veículo, conforme combinado anteriormente com o "Moisés" e voltaram logo após lhe entregando o veículo, sendo que em seguida saiu para voltar para Hortolândia, presenciando o momento em que encontraram a droga, quando alegou ainda que quando chegasse em Hortolândia devolveria o veículo para o amigo Moisés, de quem pegou o carro emprestado para ir na tia. Disse que foi dada voz de prisão, informado o réu de seus direitos e conduzido até o plantão policial. Alegou que o acusado não possuía celular no momento da abordagem. (fl. 06).

Em Juízo, disse que estavam em fiscalização na Praça de Pedágio de Catiguá e o condutor de uma Montana, identificado posteriormente como Ismael, ficava olhando para os policiais e por isso resolveram abordá-lo. Em revista pessoal, nada foi encontrado, mas ele começou a apresentar versões conflitantes e decidiram verificar o veículo. Encontraram 25 tijolos com crack, mas ele não explicou como adquiriu a droga, chegando a dizer que havia almoçado em Santa Fé e uns indivíduos pegaram o veículo e ele não sabia o que eles fizeram. Não fez contato com os policiais de Hortolândia. Não havia conhecimento prévio acerca do réu. Disse que a abordagem foi de rotina pelo nervosismo do réu. As drogas estavam nas laterais da caçamba do veículo. Pela experiência de trabalho, o pisante da caçamba já havia sido mexido diversas vezes pela disposição dos parafusos e etc. Não fizeram busca acerca do proprietário do veículo.

A testemunha Leonardo Silvestre Pereira de Souza declarou, na delegacia, que se encontrava em serviço no pedágio de Catiguá, realizando bloqueio de fiscalização de rotina, quando avistaram um veículo Montana na qual o condutor ficava olhando em direção aos policiais para ver se seria abordado, aparentando ter se assustado com o bloqueio e assim mandaram o condutor parar o veículo logo após ele passar o

pedágio sentido Catanduva, quando então mandaram o condutor descer do veículo e realizaram a busca pessoal, sendo que nada de ilegal foi encontrado. Disse que o condutor foi inquirido sobre de onde vinha e para onde estaria indo, bem como solicitada a documentação do veículo, ele apresentou documentação em ordem, mas ora dizia que vinha de Santa Fé do Sul ora que vinha de São José do Rio Preto, dizendo que estava voltando para Hortolândia, de onde tinha saído na data dos fatos. Afirmou que o réu que aparentava nervosismo e dizia que tinha ido visitar a tia da mulher dele, sendo que ele estava sozinho no veículo, quando então foram revistar o veículo e encontraram vinte e cinco tijolos de substância aparentando ser crack. Quando indagado, o autor, identificado como Ismael, alegou que parou em uma residência onde almoçou na cidade de Santa Fé do Sul e alguns rapazes saíram com seu veículo, conforme combinado anteriormente com o "Moises" e voltaram logo após lhe entregando o veículo, sendo que em seguida saiu para voltar para Hortolândia, presenciando o momento em que encontraram a droga, quando alegou ainda que quando chegasse em Hortolândia devolveria o veículo para o amigo Moisés, de quem pegou o carro emprestado para ir na tia. Disse que foi dada voz de prisão, informado o réu de seus direitos e conduzido até o plantão policial. Alegou que o acusado não possuía celular no momento da abordagem. (fl. 08).

Em Juízo, disse que estavam em fiscalização na Praça do Pedágio de Catiguá e viram que o condutor da Montana demonstrou muito nervosismo e decidiram aborda-lo. Em busca pessoal, nada foi encontrado, mas ele dava versões desconexas de onde vinha, uma hora dizia que vinha de Rio Preto e outra que vinha de Santa Fé do Sul. Decidiram fazer a busca no veículo e o depoente encontrou na lateral da caçamba o total de 25 tijolos de crack. O réu estava muito nervoso. Ele disse que almoçou na casa de um amigo em Santa Fé do Sul, de nome Moisés, e umas pessoas pegaram o veículo, colocaram a droga e o acusado iria levar para Hortolândia. O réu dava várias versões do motivo de estar fazendo a viagem. O acusado estava muito nervoso que quase caiu quando desceu do veículo. A abordagem ocorreu pela postura do réu, o nervosismo. Disse que o crack está avaliado em R\$ 50.000,00 o quilo. Não conferiu se o réu tem parente em São José do Rio Preto, pois o réu não sabia o nome da tia da esposa que ele alegou que foi na casa. A verificação do proprietário do veículo é feita pela Polícia Civil. Alegou que um quilo de crack gera em torno de 4.000 eppendorf's.

O acusado, em solo policial, declarou que saiu de Hortolândia na data dos fatos por volta das 06h30min, com destino à Santa Fé do Sul, sendo que foi atendendo a pedido de Moises e de outro rapaz. Disse que estava na Montana e eles estavam em outro veículo na frente, um Up, da VW, que tem a traseira preta, mas o carro é branco, sendo que na ida passou em São José do Rio Preto na casa da tia de sua mulher, de nome Marcia Alcântara carvalho, e continuou até Santa Fé do Sul, onde acabou indo até Três Fronteiras em uma casa indicada por Moisés e quando lá chegou, eles deixaram o interrogando nesta casa e saíram com o veículo Montana e após uma hora e pouco eles voltaram e chamaram para ir embora, assim pegou a Montana de novo, e seguiram viagem, sendo que eles foram na frente e o interrogando atrás até que chegou no pedágio de Catiguá na Whashington Luis, onde policiais estavam fazendo um bloqueio e assim pararam o réu. Alegou que disse que tinha ido para Santa Fé, mas em momento algum explicou o que foi fazer lá, alegando que foi para Santa Fé a troco de visitar a tia de sua mulher em Rio Preto. Afirmou que os policiais procederam revista pessoal e nada encontraram, mas quando eles foram revistar o veículo, encontraram na caçamba vários tijolos de drogas, dizendo que era crack. Alegou que não tinha conhecimento da droga, pois ela estava escondida na lateral da caçamba, no local onde coloca o pé para subir na carroceria, sendo que era ali que estava a droga. Disse que conheceu Moises em Campinas onde também morava e mudou para Hortolândia, acabando por encontrar Moises novamente que também se mudou para Hortolândia próximo de sua residência, sendo que mora no Bairro Santa Clara e ele mora no Remanso Campineiro, próximo ao centro. (fl. 09).

Em seu interrogatório em Juízo, disse que passou em São José do Rio Preto, na casa de uma tia da esposa, de nome Márcia, mas ela não estava e foi na casa de uma cunhada dela de nome Tânia que é esposa de um primo da esposa e depois foi para Santa Fé do Sul para pegar um carro. Foi contratado por um tal de Carlos em um

estacionamento de Hortolândia e um amigo de nome Roberto indicou o depoente para o Carlos e este pediu para pegar a Montana e levar de Hortolândia para Santa Fé do Sul e ia trazer outro carro, mas não trouxeram outro carro, trouxeram a Montana novamente. Ia receber R\$ 2.000,00 pelo transporte do veículo. Alegou que achou estranho e questionou sobre o outro veículo e o rapaz disse que não tinha dado certo. Disse que ficou nervoso, pois nunca havia sido abordado pelos policiais. Negou que tenha ficado nervoso antes da abordagem policial e foram os policiais que chamaram para aborda-lo. Não sabe se tentaram entrar em contato com as testemunhas de defesa. Disse que trabalhou muitos anos de motorista e por isso foi indicado para o Carlos. Alegou que os policiais viram o nome de Moisés no celular e é parente do réu. O Moisés não é dono do carro. Pois bem.

Não obstante a versão exculpatória do acusado, as provas coligidas aos autos são firmes a indicar a responsabilidade criminal do réu. Isso porque as testemunhas foram enfáticas e categóricas ao afirmarem que encontraram enorme quantidade de cocaína, na forma de crack, em poder do acusado.

O acusado apresentou, tanto em solo policial quanto em Juízo, uma versão desconexa e inverossímil, não demonstrando uma linha lógica de atos, o que também ocorreu quando de sua abordagem pelos Policiais Militares, sendo que esses confirmaram que o réu estava muito nervoso e apresentou versões conflitantes sobre seu trajeto e destino.

A alegação de que não sabia o conteúdo que transportava não condiz com a própria dinâmica da abordagem policial e apreensão das drogas. Isso porque os Policiais Militares foram uníssonos no sentido de que abordagem ocorreu justamente por ter o acusado demonstrado nervosismo ao avistar a viatura policial na Praça do Pedágio de Catiguá, nervosismo e apreensão decorrentes da imensa quantidade de entorpecentes que transportava.

Não se mostra crível que “umas pessoas” tenham levado o carro que era conduzido pelo réu para um lugar desconhecido e retornado, entregando ao acusado novamente o veículo, sem que o réu soubesse se havia algo de ilícito no automóvel. Insta salientar que, em Juízo, o réu afirmou que foi contratado para levar o veículo Montana que fora apreendido de Hortolândia para Santa Fé do Sul e traria para Hortolândia outro veículo, sendo que receberia R\$ 2.000,00 pelo transporte. Disse, no entanto, que não lhe entregaram outro veículo em Santa Fé do Sul, mas o mesmo veículo Montana, o que achou estranho, mas não questionou. Verifica-se que o acusado, no escopo de eximir-se de sua responsabilidade criminal, apresenta versões diversas e sem substrato fático probatório, visto que o réu nada trouxe para confirmar suas alegações.

Ante a considerável quantidade de entorpecente encontrada, no total de 25 tijolos de cocaína, na forma de crack, com peso líquido de 24,75 quilogramas (laudo de fls. 19/21 e fls. 244/246), deduz-se que o réu possui amplo envolvimento em prática delitiva e que sua função era transportar o entorpecente por ser primário e assim ser possível, teoricamente, alegar o tráfico privilegiado, como sói acontecer em casos de grandes apreensões como o que ora se apresenta. Chama a atenção que a quantidade e natureza da droga induz, inclusive, à profissionalização do acusado no narcotráfico, considerando que as organizações criminosas afetas ao tráfico de entorpecentes, ao captarem pessoas para o transporte das drogas (as intituladas “mulas”), não entregam alta quantidade de entorpecentes logo na primeira viagem, ocorrendo o aumento de forma gradual. Portanto, não prospera a alegação do réu de que não sabia que transportava entorpecentes. Sobreleva consignar que o Policial Militar Leonardo Silvestre, quando ouvido em Juízo, disse que um quilo de crack tem valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e, no caso em comento, o entorpecente apreendido valia aproximadamente R\$ 1.240.000,00 (um milhão e duzentos e quarenta mil reais) e quantidade apreendida era capaz de gerar em torno de R\$ 100.000,00 (cem mil) pedras de crack, como afirmado pelo Policial Silvestre que um quilo de crack gera em torno de 4.000 (quatro mil) eppendorf's de crack, o que não se coaduna com o tráfico privilegiado.

Assim o “prejuízo” para a organização criminosa, neste caso, foi de mais de um milhão de reais e, por certo, não haveria a entrega dessa enorme quantidade de

entorpecentes para alguém que fosse inexperiente na empreitada criminosa. Vale ressaltar, ainda, que para a configuração do crime de tráfico de entorpecentes, basta a ocorrência de um dos verbos do tipo penal (descrição da lei), o que, neste caso, constitui o fato de “transportar” os entorpecentes apreendidos, com o objetivo de comercializá-los, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Realmente, o crime de tráfico ilícito de drogas é de natureza permanente, que se consuma com a simples posse dela pelo agente para fim de entrega e consumo a terceiro sendo, portanto, desnecessário que seja flagrado vendendo o tóxico. Note-se que:

“Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrario sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (RT 584/347).

Assim, plenamente amoldada a conduta do denunciado ao tipo penal cuja autoria lhe foi imputada, visto que foi encontrado com grande quantidade de entorpecente, sendo 25 tijolos de cocaína, na forma de crack, com peso líquido de 24,75 quilogramas (cf. auto de exibição e apreensão de fl. 17, laudo de constatação de fls. 19/21 e laudo toxicológico definitivo de fls. 244/246). Não há dúvidas, portando, sobre a conduta criminosa do acusado no que se refere ao tráfico de drogas diante das provas produzidas.

Nesse contexto, comprovadas a autoria e a materialidade do delito, sendo o fato típico, antijurídico e culpável, não havendo causas que excluam a imputabilidade do réu ou o isentem de pena, de rigor a condenação nos termos constantes na peça inicial acusatória.

Passo à dosimetria da pena:

Primeiramente, ressalto que os aumentos e diminuições aplicados por meio de frações sobre a pena-base serão feitos sobre o intervalo de pena estabelecido entre a pena mínima e máxima, visando a uma pena mais justa, haja vista que aplicar a fração de aumento sobre a pena mínima pode gerar incongruências que não coadunam com o desejo do legislador, que fixou o intervalo justamente para atender ao princípio da individualização da pena. Esclarece-se, ainda, que não há tarifação dos aumentos e diminuições, os quais serão valorados segundo avaliação concreta.

Nessa esteira de entendimento, está o escólio de Ismael Almeida Ribeiro, ao discorrer sobre o tema, assevera, in verbis:

“Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada). (...) Tem sido hábito de vários juizes brasileiros, de qualquer grau de jurisdição, optar, quase sempre, pela aplicação da pena mínima aos acusado em julgamento. Desprezam-se, em verdade, os riquíssimos elementos e critérios dados pela lei penal para escolher, dentre o mínimo e o máximo cominados para cada infração penal, a pena ideal e concreta para cada réu. Não se compreende o que leva o Judiciário, majoritariamente, a eleger a pena mínima como base para a aplicação da pena em parâmetros diferenciados para os réus submetidos a julgamento. A padronização da pena é contrária à individualização, de modo a alterar essa conduta ainda predominante”. (In Código Penal Comentado, RT, 2010, 10ª Edição, p. 393 e 395).

E acrescenta:

“Mensurar a pena-base, de maneira particularizada a cada acusado, é a meta fundamental do magistrado, na sentença condenatória. Esse mecanismo deve erguer-se em bases sólidas e lógicas, buscando a harmonia do sistema, mas sem implicar em singelos cálculos matemáticos. Não se trata de mera soma de pontos ou frações como se cada elemento fosse rígido e inflexível”. (In Código Penal Comentado. 16 ed.

rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 470).
Ultrapassados tais esclarecimentos iniciais, passo, então, à individualização da pena.

Artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06:

Na primeira fase, e considerando a preponderância estabelecida no artigo 42 da Lei nº 11.343/06 (natureza e quantidade de droga), sobretudo porque o crack é substância de elevado potencial lesivo e capacidade de viciar, de grande poder degenerador da personalidade, de alto índice viciante, geradora de invencíveis problemas na saúde pública, e de conhecida potencialidade letal e ante a considerável quantidade de droga apreendida (24,75 quilos líquidos) merecendo maior resposta por parte do Estado na aplicação da pena; quanto à conduta social e a personalidade do agente, nada há nos autos a indicar devam ser tais circunstâncias valoradas negativamente; quanto às demais circunstâncias judiciais do artigo 59, caput, do Código Penal, infere-se que a culpabilidade, compreendida como grau de censurabilidade da conduta, foi aquela inerente ao crime de tráfico de drogas; o réu não possui antecedentes criminais; os motivos e circunstâncias são aqueles ínsitos ao crime. Com relação às consequências do crime, entendidas como a intensidade de lesão ou nível de ameaça ao bem jurídico tutelado, abrangendo, ademais, os reflexos do delito em relação a terceiros, não apenas no tocante à vítima, tenho-as como desfavoráveis, visto que a atitude do réu corrobora com a criminalidade na sociedade, pois o apoio ao consumo de drogas é "desencadeador" de vários outros delitos. Por se tratar de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita de comportamento da vítima. Ante tais circunstâncias, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, no piso legal cada.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não há atenuantes a serem consideradas. Incide a agravante disposta no art. 61, II, "j", do Código Penal, que se refere à calamidade pública, pois o acusado praticou delito que atenta contra a saúde pública durante a pandemia da Covid-19 que assola o país e o mundo. Salienta-se que o Congresso Nacional decretou "Estado de Calamidade Pública" por meio do Decreto Legislativo n. 06/2020, o que permite a aplicação da agravante, considerando que a conduta do réu contribui para o caos que ainda assola a população. Portanto, agravo a reprimenda anteriormente imposta em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e pagamento de 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multa, no piso legal cada.

Na derradeira fase da dosagem da reprimenda, não incidem causas de diminuição ou de aumento de pena, de forma que torno a pena definitiva no patamar anteriormente fixado.

Cada dia-multa terá valor correspondente a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente à data do fato, por ausentes elementos hábeis a comprovar a condição financeira do acusado.

Observo não ser o caso de se reconhecer a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, uma vez que ficou comprovado o envolvimento do acusado com práticas delitivas, ante a imensa quantidade de entorpecentes apreendida que ratificam sua dedicação à atividade criminosa, o que impossibilita a aplicação do redutor. Tal norma possui natureza jurídica de causa especial de diminuição de pena. A finalidade desta minorante é adequar a punição ao caso concreto, atendendo-se ao princípio constitucional de individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal) e adequar a pena prevista no preceito secundário do artigo 33, "caput", ao fato delituoso que represente menor gravidade. Ou seja, reduzida ofensa, menor perigo social, uma vez que se dirige as pessoas que não tenham envolvimento anterior com crimes e que, a despeito de terem praticado uma conduta relacionada ao tráfico de drogas, não se dediquem à traficância, o que não se verifica in casu.

A intenção do legislador ao inserir o §4º no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 foi privilegiar aquele que praticou o tráfico como um fato isolado em sua vida e não o fez como modo de vida no escopo de enriquecimento ilícito e obtenção de lucro fácil, ou seja, animus lucrandi e modus vivendi.

Nesse sentido, cumpre trazer à baila brilhante lição sobre o tema, em acórdão da lavra do i. Desembargador Geraldo Wholers (Apelação nº 0427092-39.2010.8.26.0000 - 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo):

“O propósito do legislador, certamente, não foi favorecer os traficantes de alto coturno. A mens legis da Lei nº 11.343/06 há de ter tido em vista, primordialmente, fornecedores ocasionais, que não denotam perseverança criminosa, hábito delinquencial ou gravíssimo comprometimento para a ordem social, a paz coletiva e a saúde da população em geral, virtudes certamente irreconhecíveis no imperdoável traficante de drogas que persevera nessa senda. Tanto, aliás, que o citado art. 33, § 4º, contém expressa referência, para fins de merecimento da redução condescendente, à exigência de que o agente “não se dedique às atividades criminosas”. Sabe-se que em termos repressivos o ditame constitucional é o de desestimular com energia o comércio ilegal de drogas; logo, o benefício trazido pela nova lei de regência, editada sob o mote de tornar mais rigoroso o tratamento penal que incide sobre o traficante, conflita, quando aplicado de modo indiscriminado, com a Constituição da República. Há, além da quebra do princípio de isonomia entre os condenados por outros crimes (especialmente pelos classificados como igualmente hediondos) e os condenados por tráfico de drogas, uma violação às disposições constitucionais e aos tratados internacionais que obrigam o Poder Público brasileiro à repressão efetiva do narcotráfico. A inteligência útil e legítima da norma sob análise só pode ser feita à luz da Carta Política, e nesse passo se conclui que a mercê foi estabelecida para dar solução excepcional a situações excepcionais. No âmbito desta Colenda Câmara, registrou o preclaro DES. LUIZ ANTÔNIO CARDOSO por ocasião do julgamento da Apelação Criminal nº 990.09.111160-0 (Comarca de Lucélia, j. em 25 de maio de 2010), que “essa causa de redução da pena deve incidir na excepcionalidade, em situações específicas, próprias, quando patente que o tráfico apurado cuidou-se apenas de um desvio na vida do réu, e não de uma contumácia, estilo, repetição de fato análogo, de uma rotina de proceder”. A lei atual trouxe tratamento distinto para quem oferece droga a pessoa de seu relacionamento sem objetivo de lucro - a rigor, traficante de entorpecentes: § 3º do mesmo artigo 33. Ora, também se reserva tratamento diferenciado no § 4º, pois o redutor se dirige a quem comete uma das condutas puníveis constantes do caput ou do § 1º do artigo 33 quando o agente atua sem ter o lucro por meta, sem intuito de comércio, sem adotar a odiosa e desagregadora propagação narcótica como meio de vida. É assim que se deve considerar a exigência de “não se dedicar às atividades criminosas” (terceira figura dos pressupostos indispensáveis à concessão da benesse), porque quem procura obter vantagem financeira através do mercadejo de substância clandestina se propõe, claro, a exercer atividade criminosa: presta o torpe serviço para alguém, faz a deplorável intermediação para alguém, busca aumentar os recursos ilícitos de grupos ou organizações formadas à margem da lei para custear investidas delituosas n'outros setores do submundo. Convenhamos ser fenômeno de extrema raridade o traficante que age solitariamente... Se se der outra interpretação ao dispositivo em apreço, de forma a alcançar todo e qualquer agente que preencha os demais requisitos, haverá incontornável discrepância com outras normas da mesma Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, como, por exemplo, a descrição típica de seu artigo 37 (mero informante)”. Sem grifos no original.

A benesse sob comento trata da figura do “traficante privilegiado”, também chamada de “traficância menor” ou “traficância eventual”, estabelecendo a redução de pena de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Assim, incabível, no presente caso, a aplicação da benesse pretendida.

Ainda, para ilustrar a inviabilidade de causa de diminuição de pena:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INAPLICABILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL RELATIVO À NÃO DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte de Justiça Superior tem asseverado que a expressiva quantidade e a natureza do entorpecente apreendido em

poder do acusado constitui circunstância hábil a impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, a depender das peculiaridades da hipótese concreta. In casu, tratase de apreensão de 54 pedras de crack - "50 embaladas de dez em dez e quatro avulsas" -, circunstância esta que impede a aplicação do mencionado redutor de pena. 2. Agravo regimental a que se nega provimento". (AgRg no REsp: 1302590 RS 2012/0016349-7, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, j. 11/03/2014, Colenda SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2014).

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, e assim porque a fixação de regime mais brando é insuficiente para a prevenção e a repressão da prática de crimes da natureza do cometido pelo acusado, suficiência que é norteadora também da fixação do regime inicial de cumprimento de pena (artigo 59, III do Código Penal). Lado outro, o crime de tráfico de drogas é de extrema gravidade por atentar contra a saúde pública e disseminar o vício, contribuindo efetivamente para a degradação da pessoa, da família e da sociedade, sem olvidar sua natureza de crime hediondo (art. 2º, §1º, da Lei n. 8.072/90).

Em razão da pena aplicada e do período de prisão processual até o momento, inviável a aplicação do art. 387, § 2º, do CPP, por não influenciar no regime inicial de cumprimento de pena.

De outro norte, o desconto imposto pela novel legislação deve ser ponderado à luz das regras insculpidas na Lei de Execução Penal, e não como mero cálculo aritmético isolado, sob pena de permitir ao condenado uma progressão de regime imprópria, ou seja, com lapsos temporais reduzidos e desconhecimento completo de seu mérito pessoal, em total arrepio às regras existentes, as quais, diga-se de passagem, não foram revogadas.

Desta feita, por reputar necessária uma análise mais profunda acerca do mérito do acusado, conforme ponderações supra tecidas, deixo de fixar, também por este motivo, regime prisional diverso do fechado, conforme faculta o dispositivo elencado no artigo 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO.

Do exposto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na ação penal para CONDENAR ISMAEL ALMEIDA RIBEIRO, portador da cédula de identidade RG nº 19.948.620-7 SSP/SP, filho de Antonio de Souza Ribeiro e Carmelita Almeida Ribeiro, nascido em 02/05/1967, natural em Sebastião Laranjeiras-BA, a cumprir a pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses reclusão, em regime inicial fechado; além do pagamento de 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multa, no patamar mínimo cada, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, na medida em que condenado a cumprir pena em regime inicial fechado e tendo respondido preso ao processo, sendo que mantê-lo solto, nesta altura, implicaria em claro prejuízo ao cumprimento da pena, o que demanda o acautelamento da ordem pública, impedindo a recidiva criminosa, ante seu envolvimento com atividades criminosas. Além disso, a concessão da liberdade ou a imposição de medida cautelar não privativa de liberdade coloca em risco a aplicação da lei penal, pois o réu, facilmente, poderá deixar o distrito da culpa, mormente pela quantidade de pena aplicada. Mantenho, assim, a prisão cautelar do acusado, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Expeça-se mandado de prisão em desfavor do acusado (nos termos do Comunicado CG nº 76/2016).

Condene o réu, ainda, a pagar as custas do processo, no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs (artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003), ressaltando que eventual causa de isenção melhor ser apurada pelo Juízo da Execução.

Promova-se a incineração dos entorpecentes apreendidos acaso não tenha sido realizada.

Nos termos do artigo 63, da Lei 11.343/06, declaro a perda, em favor da União, do valor de R\$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais - fl. 171) e do veículo Chevrolet Montana LS, Placa ETW 6166, Chassi 9BGCA80X0CB147141, conforme auto de apreensão de fl. 17. Expeça-se o necessário, oficiando-se ao SENAD, após o trânsito em julgado,

nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/2006.

Passada em julgado esta sentença:

Expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD).

Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para o cumprimento do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Registre-se eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Tabapua, 02 de março de 2022.

Patrícia da Conceição Santos

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA